

1501156-67.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cássio Henrique Dolce de Faria

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... do acusado Daniel confissão de tráfico. Na última fase, não há causas de aumento, nem de diminuição de pena. A birreincidência específica e os maus antecedentes do corréu Daniel são objetivamente incompatíveis com o que se convencionou chamar de tráfico privilegiado. São penas finais, assim, aquelas acima cominadas. Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Jd. Panambi, Santa Bárbara d'Oeste - 13450-515 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501156-67.2021.8.26.0630

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2351567/2021 - 2º Distrito

Policia de Santa Barbara D'Oeste, 22155737 - 2º Distrito Policia de Santa Barbara D'Oeste, 2351567 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 1753/21/925 - 02º D.P. SANTA

BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DOS SANTOS SOUZA e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Réu Preso

Aos 04 de abril de 2022, às 15:00h, em audiência realizada por videoconferência pela 2ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste, Comarca de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. CASSIO HENRIQUE DOLCE DE FARIA, comigo, escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, ingressaram na audiência virtual o representante do Ministério Público Dr. Rodrigo Aparecido Tiago, os acusados e o defensor Dr. Marcos Luciano Claudine Pomaroli OAB 279615/SP, todos devidamente intimados e após responderem de forma positiva ao convite enviado pelo programa Microsoft Teams. Em seguida, foi concedida entrevista privada entre os acusados e seu advogado por meio da sala virtual, com a garantia do sigilo da comunicação, permanecendo os demais em espera. Após a entrevista, houve o retorno deste servidor-organizador, do Magistrado e do representante do Ministério Público à audiência virtual. Como primeiro ato, todos os integrantes exibiram documento de identificação pessoal com foto. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos, etc. 1) Tendo em vista o disposto no Decreto n.º 8.858/16 e na Súmula Vinculante n.º 11, do Supremo Tribunal Federal, justifico que houve manutenção das algemas para a garantia da integridade física de todos os participantes da

audiência, principalmente das pessoas que se encontram na sala de videoconferências do centro de detenção provisória em questão, vez que a segurança daquele local é realizada por reduzido número de agentes. Nesse sentido: “a excepcionalidade do uso de algemas, consignada principalmente na Súmula Vinculante 11, do STF - que dispõe que só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito - não obsta o seu emprego se demonstrados os riscos nela previstos” (STJ, RHC: 39729 SP 2013/0241579-3, relator ministro Moura Ribeiro, julgado em 3 de setembro de 2013). 2) Conforme decidido no H.C. n.º 127.900/STF, determino que o interrogatório do réu seja o último ato da instrução. 3) Esta audiência será realizada excepcionalmente por meio virtual, na forma do Comunicado C.G. n.º 284/2020, diante da pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso de pessoas ao prédio do fórum local, sendo que as gravações serão vinculadas a este termo de audiência”. A seguir, procedeu-se à oitiva de duas testemunhas arroladas em comum pela acusação e pela defesa do corréu Daniel, bem como aos interrogatórios dos réus, conforme gravações de áudio e vídeo realizadas através do programa Microsoft Teams, que serão vinculadas a este termo de audiência. Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi dito: “Vistos, etc. Declaro encerrada a fase de instrução processual. Aos debates, de imediato”. Depois disso, passou-se aos debates orais em audiência, ainda conforme gravações de áudio e vídeo realizadas através do programa Microsoft Teams, que serão vinculadas a este termo de audiência, sendo que pelo Ministério Público, os principais pedidos foram: a parcial procedência da pretensão inicial, com a condenação apenas do corréu Daniel e a absolvição por falta de provas de sua litisconsorte. No tocante à dosimetria, pugnou por exasperação da pena-base, em razão da natureza das drogas apreendidas e de maus antecedentes, pelo reconhecimento da birreincidência específica, pela vedação ao tráfico privilegiado, por fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal, pela manutenção da segregação cautelar e pelo perdimento de todos os bens apreendidos, enquanto que pela defesa, os principais pedidos foram: a absolvição de ambos os acusados, por falta de provas, ou a desclassificação da conduta para uso. De resto, pugnou pela menor pena e pelo regime mais brando possíveis. Na sequência, o MM. Juiz proferiu a sentença nos seguintes termos: “Vistos, etc. DANIEL DOS SANTOS SOUZA e JOCIMARA ANTUNES DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. E isso porque, de acordo com a denúncia de fls. 1/3, no dia 27 de dezembro de 2021, por volta de 21h00min, na Rua do Ósmio, n.º 875, Vila Mollon, nesta cidade e comarca, eles, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando ao resultado comum, traziam consigo e transportavam, no interior do veículo Fiat/Uno Mille SX, de placas CIY-4118, desta cidade, 38 porções de cocaína, na forma de crack, com cerca de 8,0 gramas, tudo para fins de entrega a consumo de terceiros, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Os acusados foram notificados (fls. 124 e 126) e apresentaram defesas prévias (fls. 128/139 e 144/145). A denúncia foi recebida no dia 15 de fevereiro de 2022 (fls. 148/149). Os acusados foram citados (fls. 186 e 194). Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, tendo sido os acusados interrogados, em seguida. Encerrada a instrução, em debates: I) o Ministério Público pediu a parcial procedência da pretensão inicial, com a condenação apenas do corréu Daniel e a absolvição por falta de provas de sua litisconsorte. No tocante à dosimetria, pugnou por exasperação da pena-base, em razão da natureza das drogas apreendidas e de maus antecedentes, pelo reconhecimento da birreincidência específica, pela vedação ao tráfico privilegiado, por fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal, pela manutenção da segregação cautelar e pelo perdimento de todos os bens apreendidos; II) a defesa pediu a absolvição de ambos os acusados, por falta de provas, ou a desclassificação da conduta para uso. De resto, pugnou pela menor pena e pelo regime mais brando possíveis. É o relatório. Fundamento e decido. Não há matéria preliminar pendente de apreciação. No mérito, a pretensão inicial procede em parte, pelos fundamentos expostos a seguir. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo

boletim de ocorrência de fls. 12/14, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, pelo auto de constatação preliminar de fls. 19/20 e, finalmente, pelo laudo químico toxicológico de fls. 170/172, além da prova oral colhida. Há, também, prova suficiente de autoria em desfavor do corréu Daniel, como se demonstrará a seguir. Na polícia, os corréus preferiram o silêncio (fls. 10/11). Em juízo, o corréu Daniel disse que as drogas compradas eram para seu consumo. Comprou dez gramas de crack, na biqueira, no Jardim Romano, por R\$ 225,00. Os R\$ 20,00 que então teriam sobrado foram utilizados para abastecer o veículo, seu instrumento de trabalho (cata reciclagens). Quando comprou a droga, sua esposa não estava com ele. Depois disso, já trazendo a droga em seu bolso, ele e sua esposa (corré) foram vender um pouco de material para reciclagem, recebendo por isso R\$ 314,00 ou R\$ 315,00. Ato contínuo, eles foram para o drive, para lá pernoitar. Consumiu entorpecentes com a esposa no drive (4 ou 5 pedras de crack). O restante da droga era seu, para consumo, também. Ele havia escondido da esposa essa droga, porque ela usa mais do que ele. Estava embriagado, alucinado pelo entorpecente e também sem CNH. Sobre seu veículo existiam pendências. Por isso, fugiu da abordagem policial. Durante a fuga, do lado do motorista, a porta de trás do veículo abriu, porque ela ficava meio solta. Devido a isso, começaram a sair sacolinhas de reciclagem e alguns alimentos pelo automóvel. Finalizou, dizendo que tem ressalvas com relação ao policial Ed Carlos e se sente perseguido pela polícia de Santa Bárbara d'Oeste desde 2006, em razão de seus problemas com drogas. Já Jocimara, em juízo, disse que não sabia que tinha mais pedras de crack no veículo, porque senão ela as teria consumido. Asseverou não se recordar de quanta droga havia usado, porque também estava embriagada na data do crime. Afirmou que usava mais drogas do que o seu marido e que, atualmente, está fazendo tratamento de desintoxicação. Embora não se recorde de ter feito isso no dia dos fatos, ela aduziu que passava na rua quase que diariamente para pegar papelão e que vendia o produto da venda praticamente todo dia. Finalizou, dizendo que: a) só se recorda da existência de policiais perseguindo o veículo deles (que usavam para coletar), quando então teria falado para seu marido (corréu) correr e parar em um local movimentado, para que não lhes fizessem mal; b) segundo aquilo que se lembra, nada teria sido jogado do veículo, durante a perseguição; c) não se lembra se tinha muita coisa no banco de trás do veículo. Em suma: o próprio corréu Daniel confessou que trazia consigo/transportava as drogas encontradas, remanescendo controvérsia apenas sobre a finalidade de sua conduta. Neste ponto, as teses de autodefesa, naquilo delas em que há a tentativa de atenuar a responsabilidade do corréu Daniel, estão isoladas no conjunto probatório. Senão vejamos. De início, há que se ponderar que pesa em desfavor dos réus a situação comprometedor derivada de sua prisão em flagrante, transportando consigo, no veículo dirigido por Daniel e que tinha a corré como passageira, entorpecentes embalados em porções individuais e razoável quantidade de dinheiro. Há, em adição, o relatado pelos policiais militares Ed Carlos e Rogério, que, em depoimentos coerentes em sua essência e complementares entre si, prestados na delegacia (fls. 5/7) e em juízo, confirmaram que: a) estavam em patrulhamento, oportunidade em que avistaram o veículo Fiat/Uno Mille SX, de placas CIY4118, em alta velocidade. Este veículo, com a aproximação da viatura, tentou se evadir; b) foi dada a ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, mas o condutor do veículo

continuou o percurso sentido à zona leste; c) durante a fuga, foram arremessados objetos (sacolas) sobretudo pela janela do lado do motorista do veículo perseguido. Essas embalagens plásticas pareciam conter algum pó branco, mas não foi possível recuperar aquilo arremessado; d) realizado o cerco, foi possível abordar o veículo em que estavam os acusados. O corréu Daniel era o condutor e a corré Jocimara ocupava o assento dianteiro do passageiro; e) foram localizados no interior do automóvel: 1º) embaixo do banco do motorista, um tubo plástico contendo 38 porções de crack; 2º) R\$ 214,00, em dinheiro, sobre o banco do passageiro; f) indagados, os réus: 1º) negaram a propriedade das drogas encontradas, embora tenham dito que são usuários e que tinham feito uso pretérito de entorpecentes; 2º) nada disseram sobre o que teriam arremessado para fora do automóvel; 3º) disseram que o dinheiro encontrado era fruto de seu trabalho na reciclagem; 4º) alegaram que tentaram fugir

porque o veículo não estava com a documentação em ordem; g) diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão em flagrante delito; h) o local em que os réus foram abordados não é próximo de ponto de venda de drogas. Não há motivo algum para que seja negada credibilidade aos relatos dos policiais militares, com quem os corréus não demonstraram a existência de nenhuma animosidade. Tais relatos são suficientes para fundamentar a sentença condenatória, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vide, a propósito, o decidido no Habeas Corpus n.º 395.325/SP, pela Quinta Turma daquela Corte, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 18 de maio de 2017. Pequenas contradições, referentes a aspectos periféricos da conduta, são inerentes ao psiquismo humano. Não têm o condão de minar a credibilidade do declarado pelos policiais militares, até mesmo porque não é crível a suposição de que agentes públicos que têm por dever funcional a manutenção da lei e da ordem viriam a juízo mentir (respondendo inclusive penalmente por sua conduta) para incriminar terceiros. Diante desse conjunto: 1º) como bem ponderado pelas partes, a prova existente em desfavor da corré Jocimara é por demais frágil para a condenação, na medida em que ambos os acusados negaram que ela tivesse conhecimento das drogas adicionais encontradas no veículo e os policiais não afirmaram com a segurança necessária ter presenciado descartes de possíveis entorpecentes pelo lado do veículo em que ela estava. Destarte, para ela, impõe-se a absolvição, com base no in dubio pro reo; 2º) há, por outro lado, o suficiente para a condenação do corréu Daniel pela imputação descrita na denúncia. Afinal, após admitir que trazia consigo/transportava as drogas apreendidas, este réu apresentou versão pouco crível para sustentar sua tese acerca da destinação dos entorpecentes. Isso porque não é razoável se esperar que agente que tem repleto passado criminal, recheado do envolvimento com entorpecentes, carregasse consigo, ao longo de várias horas de um dia, entorpecentes em quantidade adicional à que desejaria consumir, se essa fosse a real intenção que ele pretendia dar às drogas. Esta constatação, agregada ao comprovado descarte daquilo que possivelmente consistia em mais drogas ocorrido durante a perseguição e às circunstâncias que cercaram a prisão em flagrante (razoável quantidade de drogas escondidas debaixo do banco do assento do veículo ocupado pelo corréu Daniel; todas as drogas estavam embaladas em porções individuais; houve, também, apreensão de dinheiro, em quantidade aparentemente incompatível com os parcos rendimentos obtidos por catadores de papel, quando da recepção da remuneração por suas coletas. Quanto ao ponto, deve-se mencionar que o recibo de fls. 137 absolutamente nada prova, até porque o seu signatário não foi arrolado para estabelecer a existência de suposta vinculação à quantia estampada no instrumento) forma conjunto suficiente para demonstrar a finalidade mercantil na conduta imputada ao corréu Daniel. Logo, para ele, o desate condenatório pela imputação descrita na denúncia é medida de rigor, não havendo espaço para absolvição ou para desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei de Drogas. Aliás, nada impede que usuários de drogas sejam, concomitantemente, traficantes, o que pode ter ocorrido na situação ora julgada. Posto isso, impõe-se a parcial procedência da essência da versão acusatória. Passo, agora, à dosimetria das penas, em atenção aos vetores específicos do artigo 42, da Lei de Drogas. Foram apreendidas trinta e oito porções de crack, acondicionadas em invólucros papel alumínio (fls. 15). A quantidade total, pouco superior a 3 gramas líquidos (3,9 gramas de massa líquida de crack – fls. 170/172), é tolerada sem exasperação da pena-base pelo que constitui a média da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tanto não procede a tese acusatória de que o encontro de pequena quantidade de crack justificaria a exasperação da pena-base que há precedente da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 503.848/MS, no seguinte sentido: “(...) 2. Ainda que considere nociva a natureza da droga apreendida, evidenciada a quantidade não relevante (32,93g de cocaína) e ausentes circunstâncias adicionais – inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, etc. –, não é razoável a exasperação da pena-base” (relator ministro Nefi Cordeiro, julgado em 27 de agosto de 2019). Por outro lado, verifico que o réu Daniel tem contra si quatro condenações transitadas em julgado (excluída uma por porte de drogas, que

será desconsiderada na dosimetria). Por isso, uso como maus antecedentes as condenações: a) verificada no processo de execução penal n.º 7001710-41.2007.8.26.0114 (execução n.º de ordem 1 constante da folha de antecedentes do réu - fls. 45); b) emanada do processo de conhecimento n.º 0001174-56.2007.8.26.0533, cuja certidão se encontra a fls. 48 (a pena alusiva a este feito ainda está com execução em aberto, pelo que se vê do processo de execução penal n.º 7000259-93.2010.8.26.0269 (execução n.º de ordem 2 constante da folha de antecedentes do réu - fls. 46). Saliento que: a) o uso de condenações antigas e até mesmo prescritas para fins de reincidência na primeira fase da dosimetria foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 593.818/SC (tema n.º 150); b) essas condenações não serão consideradas para fins de reincidência, de modo que esta decisão respeita e se mostra de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula n.º 241, do Superior Tribunal de Justiça. Fincadas essas balizas, fixo a pena base do corréu Daniel um sexto acima do mínimo, em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Na segunda fase, o corréu Daniel é birreincidente específico, considerando suas condenações pretéritas atinentes aos processos de conhecimento n.º 0000519-11.2012.8.26.0533 (certidão a fls. 48) e n.º 0017551-68.2008.8.26.0533, cuja certidão se encontra a fls. 49 (a pena alusiva a este feito ainda está com execução em aberto, pelo que se vê do processo de execução penal n.º 7000002-34.2013.8.26.0602 - execução n.º de ordem 3 constante da folha de antecedentes do réu - fls. 46). A jurisprudência majoritária do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entende que uma reincidência específica autoriza o aumento de um quinto na pena, duas de um terço e assim por diante. Por consequência, aumento as penas até aqui cominadas em um terço, o que resulta em sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e setecentos e setenta e sete dias-multa. Não há atenuantes, incidindo na hipótese o entendimento sedimentado na Súmula n.º 630, do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não houve por parte do acusado Daniel confissão de tráfico. Na última fase, não há causas de aumento, nem de diminuição de pena. A birreincidência específica e os maus antecedentes do corréu Daniel são objetivamente incompatíveis com o que se convencionou chamar de tráfico privilegiado. São penas finais, assim, aquelas acima cominadas. Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal, por ser o único compatível com os maus antecedentes e a birreincidência específica do corréu Daniel. O montante de pena fixado impede a substituição da sanção corporal e a concessão de sursis. Valor unitário do dia-multa no piso legal. Desnecessárias outras observações. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO INICIAL desta AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para: I) ABSOLVER JOCIMARA ANTUNES DOS SANTOS, qualificada nos autos, da imputação constante da denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; II) DAR DANIEL DOS SANTOS SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, cumulado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal. Por conseguinte, CONDENO-O: a) a sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado; b) ao pagamento de setecentos e setenta e sete dias-multa, de valor unitário mínimo. Condeno o corréu Daniel, ainda, ao pagamento da taxa judiciária, mas condiciono a exigibilidade dessa verba ao sistema do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, porque aos acusados devem ser deferidos os benefícios da justiça gratuita, diante daquilo por eles relatado em seus interrogatórios. Anote-se. O corréu Daniel respondeu preso ao processo, com os requisitos e fundamentos que tinham motivado sua segregação cautelar apenas sendo reforçados com esta decisão. Denego-lhe, em consequência, o direito de recorrer em liberdade. Recurso em liberdade para a corré Jocimara, revogadas eventuais medidas cautelares diversas da prisão anteriormente cominadas. Após o trânsito em julgado: a) lance-se o nome do corréu Daniel no rol dos culpados, comunicando-se esta decisão ao Tribunal Regional Eleitoral; b) expeça-se guia de execução definitiva; c) expeça-se o necessário para a reversão em favor do Fundo Nacional Antidrogas do dinheiro, do veículo e dos demais bens apreendidos em poder do acusado Daniel, cujo perdimento ora determino, com fundamento no artigo 63, inciso I, da Lei de Drogas, por

considerá-los vinculados à ação criminosa; d) autorizo a destruição de eventual remanescente de cada substância apreendida. Cumpridas as alíneas anteriores, arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Dispensado o registro (Provimento CG n.º 27/2016). Cumpra-se. Nada mais". Em seguida, foi renovado o direito de entrevista privada entre os réus e seu advogado por meio da sala virtual, com a garantia do sigilo da comunicação, permanecendo os demais em espera. Após a entrevista, houve o retorno deste servidor-organizador, do Magistrado e do representante do Ministério Público à audiência virtual.

Com recurso(crime)

Pela defesa da corré Jocimara e pela sentenciada foi dito não haver interesse em interpor recurso, enquanto que pela defesa do corréu Daniel e pelo sentenciado foi dito haver interesse em recorrer. Por fim, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos, etc. 1) Homologo a renúncia ao recurso pela defesa da corré Jocimara. 2) Recebo o recurso interposto pela defesa do corréu Daniel nesta data, saindo o defensor intimado para oferecer as razões no prazo legal, independente de nova intimação. Após, abra-se vista ao Ministério Público para as contrarrazões. Processado regularmente o recurso, cumpra-se o disposto nos Provimentos n.º 07/2007 e n.º 08/2011, remetendo-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens. Anote-se. Expeça-se guia de recolhimento provisória em nome do réu, remetendo-a regularmente instruída à Vara das Execuções Criminais competente". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do artigo 25, caput, da Resolução n.º 185/13, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça. Os presentes saem intimados. Nada mais. Eu, KAREN CRISTINE ROSSI MENDES, digitei.

MM. Juiz: (assinado digitalmente).